

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANILAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 05-02-2025 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processo: TC-024737.989.24-4.

Representante: José Eduardo Bello Visentin.

Representada: Prefeitura Municipal de Itanhaém.

Assunto: Exame de pedido de medida cautelar no âmbito do Pregão Eletrônico nº 60/2024, que tem por objeto a *“contratação de empresa especializada em serviços de nutrição e alimentação, com operacionalização, produção e transporte nas dependências e responsabilidade da contratada, e distribuídas nas dependências de Pronto Atendimento Infantil (UPA), Pronto Atendimento Adulto (UPA), Centro de infectologia de Itanhaém (CINI), Centro de Atenção Psicossocial (II, infantil, AD)”*.

Responsável: Tiago Rodrigues Cervantes (Prefeito).

Subscritor do edital: Marcelo Gonçalves Jesus (autoridade competente).

Advogados cadastrados no e-TCESP: José Eduardo Bello Visentin (OAB/SP nº 168.357), Jorge Eduardo dos Santos (OAB/SP nº 121.023).

=====

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO TÉCNICA EM ATIVIDADES ESPECÍFICAS. AFRONTA À SÚMULA Nº 30. VEDAÇÃO À SUBCONTRATAÇÃO. IMPRECISÃO SOBRE A VISTORIA PRÉVIA DAS LOCALIDADES LICITADAS. CARÊNCIA DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O TIPO DE CONTRATAÇÃO PRETENDIDA. BASE DE CÁLCULO EQUIVOCADA PARA A PROVA DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO E GARANTIA CONTRATUAL. CARÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA

O DIMENSIONAMENTO DO OBJETO. PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1 - RELATÓRIO

1.1 Trata-se do **exame de pedido de medida cautelar** no âmbito do Pregão Eletrônico nº 60/2024, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**, cujo objeto é a *“contratação de empresa especializada em serviços de nutrição e alimentação, com operacionalização, produção e transporte nas dependências e responsabilidade da contratada, e distribuídas nas dependências de Pronto Atendimento Infantil (UPA), Pronto Atendimento Adulto (UPA), Centro de Infectologia de Itanhaém (CINI), Centro de Atenção Psicossocial (II, infantil, AD)”*.

1.2 Insurgiu-se o **REPRESENTANTE** contra os seguintes aspectos do instrumento convocatório:

- a) exigência de *expertise* em atividades específicas¹ (refeições para pacientes e para funcionários), em desrespeito à Súmula nº 30;
- b) imprecisão quanto à necessidade de apresentação de alvará sanitário², documento que entende ser obrigatório;

¹ 6.8 Qualificação Técnica

6.8.1 Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestado(s) expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, comprovando que a licitante forneceu/executou, bens/serviços com características semelhantes e compatíveis com o objeto do Edital. 6.8.1.1 A qualificação técnica deverá ser demonstrada por meio de atestados e conter no mínimo 50% (cinquenta por cento) das parcelas dos itens de maior relevância.

6.8.1.2 Itens de maior relevância:

3	UN	12.000	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO - ALMOÇO - PACIENTES - CONFORME TR
5	UN	10.200	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO - JANTAR - PACIENTES -CONFORME TR
7	UN	57.600	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO - ALMOÇO-FUNIONÁRIOS -CONFORME TR
8	UN	36.000	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO - JANTAR - FUNCIONÁRIOS - CONFORME TR

² 6.8.2 Apresentação do alvará sanitário, se a ele tiver vinculada a atividade da proponente.

- c) imposição de patrimônio líquido³ e garantia contratual⁴, sem deixar claro que a base de cálculo deve considerar um ano de ajuste;
- d) desarrazoado impedimento à subcontratação⁵;
- e) discrepância entre o subitem 4.5.1⁶ do Termo de Referência, que aponta não haver a necessidade de visita técnica, e o subitem 8.5.1⁷ que requer declaração de que a licitante tomou conhecimento das condições locais;
- f) indevida previsão de que *“a futura contratada terá de arcar com o bônus ou o ônus de situações de impossibilidade de se antecipar fatores imprevistos e alheios”*⁸;
- g) inadequada exigência de certidão negativa de insolvência civil⁹;
- h) ausência de levantamento de mercado e de estudos acerca das opções existentes para o objeto que se pretende contratar.

1.3 Por vislumbrar indícios concretos de restrição à ampla participação de interessados, requisitei, com fundamento no artigo 169, § 2º, da Lei nº 14.133/21, cópia do edital para exame previamente à realização do certame.

³ 6.9.4 Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação;

⁴ 4.4. No ato da convocação para a assinatura do instrumento, será exigida a garantia contratual no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, conforme art. 98 da Lei nº 14.133/2021.

⁵ 4.2. Subcontratação:

4.2.1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

⁶ 4.5. Vistoria:

4.5.1. Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços, no entanto, a fiscal técnica do contrato (CONTRATANTE) deverá ter livre acesso as dependências da CONTRATADA para fiscalização durante toda a vigência do contrato, desde que essa cumpra as normas de higiene e paramentação para adentrar as dependências;

⁷ 8.5. Qualificação Técnica 8.5.1. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

⁸ 5.2.6. O quantitativo de refeições solicitadas diariamente pode variar em 10%, para mais ou para menos, ficando a cargo da CONTRATADA arcar com o bônus/ônus de situações onde haja impossibilidade de se antecipar a fatores imprevistos e alheios;

⁹ 8.4. Qualificação Econômico-Financeira

8.4.1. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, ou de sociedade simples;

1.4 Regularmente notificada, a **Administração** anuiu em excluir a requisição de prova de *expertise* específica para a nutricionista e retirar a exigência de certidão negativa de insolvência civil.

Também comunicou que o Termo de Referência será retificado para: indicar as condições para apresentação do alvará sanitário e acesso às dependências da contratada (item 4.4.1)¹⁰; permitir a subcontratação apenas em casos emergenciais abruptos e imprevistos, como pandemias, endemias, surtos ou acidentes coletivos (item 4.2.1)¹¹; substituir a palavra "*local*" por "*legais*" na declaração solicitada, afim de conferir maior precisão e clareza na redação (item 8.5.1)¹²; e prever tolerância de até 40 minutos de atraso inicial na distribuição das refeições (5.2.6.1)¹³.

Por outro lado, defendeu que a imposição de garantia contratual de 5% do valor global do contrato está em conformidade com o artigo 98 da Lei nº 14.133/2021, que permite à Administração requisitá-la para assegurar a fiel execução do ajuste e minimizar riscos de inadimplência.

Outrossim, sustentou que as informações acerca do levantamento de mercado e dos estudos sobre as opções existentes para o objeto licitado estão devidamente contempladas no Estudo Técnico Preliminar (ETP), anexado

¹⁰ 4.4. Vistoria:

4.4.1. Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços, no entanto, deverá ser apresentado alvará sanitário prévio à execução dos serviços, bem como a garantia de acesso as dependências da CONTRATADA, pela fiscal técnica do contrato para fiscalização durante toda a vigência do contrato (contratante) para fiscalização durante toda a vigência do contrato, desde que essa cumpra as normas de higiene e paramentação para adentrar as dependências. (grifei)

¹¹ 4.2 Subcontratação:

4.2.1. Será admitida a subcontratação do objeto contratual somente em casos emergências abruptos e imprevisíveis (pandemia, endemia, surtos e acidentes coletivos).

¹² 8.5 Qualificação Técnica

8.5.1 – Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições legais para o cumprimento das obrigações da licitação.

¹³ 5.2.6 O quantitativo de refeições solicitadas diariamente pode variar em 10%, para mais ou para menos, ficando a cargo da CONTRATADA arcar com o bônus/ônus de situações onde haja impossibilidade de se antecipar a fatores imprevistos e alheios;

5.2.6.1 Em casos de variações superiores a 10% no quantitativo das refeições, será tolerado o atraso inicial na distribuição das refeições de até 40 minutos para adequação do serviço, bem como, a substituição do cardápio previamente aprovado para o dia, por preparação de fácil preparo (julgamento dado pela contratada), desde que constante neste edital e aprovado pela fiscal do contrato

ao processo. Sobre o tema, recordou que o TCU, no Acórdão 2273/24, destacara que a Lei nº 14.133/21 não obriga a publicação do ETP no edital de licitação.

1.5 O Ministério Público de Contas pronunciou-se pela parcial procedência das impugnações.

Considerou ser injustificada a exigência da comprovação de experiência anterior no fornecimento de refeições “*para pacientes*” e “*para funcionários*”, uma vez que os cardápios para os dois grupos são equivalentes, à exceção da periodicidade da sobremesa dos funcionários.

Avaliou prosperarem as queixas relativas à carência de requisição do alvará sanitário e à exigência de certidão negativa de insolvência civil, ante o reconhecimento das falhas pela Municipalidade.

Acolheu a crítica direcionada à base de cálculo adotada para a prova de patrimônio líquido mínimo e para a garantia de execução requisitada, que remete ao valor total do ajuste (com vigência de 60 meses), pois o correto seria utilizar o valor anual da contratação como parâmetro.

Sopesou que, apesar de o edital permitir a participação de consórcios, também deve possibilitar a subcontratação de serviços acessórios, como a higienização e manutenção predial, a fim de ampliar a competitividade no certame.

Quanto à visita técnica, constatou inexistir a alegada discrepância entre os itens 4.5.1 e 8.5.1 do Termo de Referência, porquanto, o primeiro, refere-se à vistoria a ser realizada pela contratante nas dependências da contratada, para aferição do cumprimento das normas de higiene e paramentação, após a assinatura do contrato, enquanto, o segundo, alude à vistoria prévia pelas licitantes no local de execução do serviço, que pode ser substituída por declaração formal assinada por responsável técnico.

Apesar disso, pontuou que o anúncio da substituição da palavra “local” por “legais”, no item 8.5.1 do Termo de Referência, *“denota que o conhecimento prévio do local de execução dos serviços não seria imprescindível, o que dispensaria a realização de vistoria prévia”*. Concluiu, por isso, que a Prefeitura deve definir claramente se a vistoria será ou não obrigatória, assim como fornecer todas as informações necessárias para o correto dimensionamento dos custos de execução do serviço.

Quanto à alocação de todos os ônus decorrentes de eventos imprevisíveis e atípicos à futura contratada, ponderou ser desproporcional, devendo ser revista, de forma a garantir a possibilidade de pagamento pelas refeições efetivamente fornecidas.

Por fim, acolheu as justificativas da Prefeitura de que a análise das alternativas possíveis para a escolha do tipo de solução a contratar consta do Estudo Técnico Preliminar (ETP), sendo que a NLLC não obriga sua publicação ou que conste como anexo do edital.

Todavia, destacou que *“os itens 2.1¹⁴ e 3.1¹⁵ do Termo de Referência indicam que os Estudos Técnicos Preliminares constam como ‘apêndice deste Termo de referência’, a demandar a inclusão dos referidos Estudos dentre os anexos do texto convocatório ou a exclusão dos dispositivos em questão”*.

É o relatório.

2. PRELIMINAR

¹⁴ 2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste termo de referências.

¹⁵ 3.1. A Descrição da solução como um todo se encontra pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste termo de referências.

2.1 Preliminarmente, peço ao E. Plenário que, nos termos do artigo 219-B, parágrafo único, do Regimento Interno, seja referendado o despacho por meio do qual foi concedida a cautelar pleiteada, determinando, liminarmente, a paralisação do certame.

3. VOTO

3.1 A Prefeitura Municipal de Itanhaém pretende a “*contratação de empresa especializada em serviços de nutrição e alimentação, com operacionalização, produção e transporte nas dependências e responsabilidade da contratada, e distribuídas nas dependências de Pronto Atendimento Infantil (UPA), Pronto Atendimento Adulto (UPA), Centro de Infectologia de Itanhaém (CINI), Centro de Atenção Psicossocial (II, infantil, AD)*”.

3.2 No entanto, parte das falhas suscitadas na inicial foi reconhecida pela Administração, mostrando-se incontroversa a necessidade de se retificar o instrumento convocatório, a fim de que se amolde às diretrizes da legislação de regência e à jurisprudência desta Corte.

Refiro-me à indevida exigência de certidão negativa de insolvência civil – *pois se trata de comprovante afeto à pessoa física ou jurídica não empresária (sociedade simples), enquanto o certame se destina à contratação de empresa –*, à carência de requisição do alvará sanitário – *documento obrigatório em contratação que envolve manipulação e preparo de gêneros alimentícios (conforme art. 10, inc. IV, da Lei 6.437/1977)*¹⁶ – e à imposição de prova de expertise em atividades

¹⁶ Art. 10 - São infrações sanitárias: (...) IV - extrair, produzir, fabricar, transformar, preparar, manipular, purificar, fracionar, embalar ou reembalar, importar, exportar, armazenar, expedir, transportar, comprar, vender, ceder ou usar alimentos, produtos alimentícios, medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, produtos dietéticos, de higiene, cosméticos, correlatos, embalagens, saneantes, utensílios e aparelhos que interessem à saúde pública ou individual, sem registro, licença, ou autorizações do órgão sanitário competente ou contrariando o disposto na legislação sanitária pertinente: pena - advertência, apreensão e inutilização, interdição, cancelamento do registro, e/ou multa;

demasiadamente específicas – já que não há particularidade no Termo de Referência que justifique a distinção entre o fornecimento de refeições no almoço ou jantar, ou entre pacientes e funcionários, pois os cardápios são todos equivalentes.

3.3 Outrossim, com o MPC, verifico que, “além do serviço principal de fornecimento de alimentação, a contratada será responsável por serviços que parecem acessórios ao objeto principal, a exemplo da ‘higienização das dependências’¹⁷ e da ‘manutenção, adaptação e adequação predial’¹⁸, não relacionados diretamente com a preparação dos alimentos, e que poderiam ser prestados por empresas especializadas”.

Deste modo, compreendo que a situação reclama, de fato, a necessidade de se permitir a subcontratação dos serviços assessórios, garantindo que fornecedoras aptas a executar a atividade principal possam participar da disputa, ainda que tenham que relegar a terceiros os serviços marginais.

3.4 Também merece reparo o parâmetro adotado para a demonstração do patrimônio líquido mínimo e da garantia contratual, que remetem ao valor total do contrato (com vigência de 60 meses), pois o correto seria utilizar, para o primeiro, o valor anual estimado da contratação correspondente, como dispõe a Súmula nº 37; enquanto, para o segundo, o valor anual do contrato para definição e aplicação do percentual previsto, conforme o parágrafo único do artigo 98 da Lei nº 14.133/2021.

3.5 De igual modo, deve ser revista a indevida atribuição à futura contratada de arcar com todos os ônus decorrentes de eventos imprevisíveis e atípicos, porquanto, além de sua desproporcionalidade, tais riscos certamente

¹⁷ 1.3.7. O objeto também inclui a higienização das dependências, utensílios e equipamentos utilizados;

¹⁸ 1.3.2. A manutenção, adaptação e adequação predial, que se fizerem necessárias nas dependências e instalações do serviço de nutrição e dietética a ser realizada pela CONTRATADA

serão considerados pelas interessadas em suas propostas, prejudicando a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Neste ponto, acompanho a conclusão do MPC de que deve ser assegurado o eventual *“pagamento pelas refeições efetivamente fornecidas, garantindo-se, ainda, a possibilidade de restabelecimento do ‘equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato’*, conforme art. 124, inc. II, alínea ‘d’, da Lei 14.133/2021”.

3.6 Avalio, ainda, prosperar a aventada incongruência do Termo de Referência acerca da vistoria técnica.

Isto porque, o mencionado item 4.5.1, ao tratar especificamente do tema, prevê expressamente que *“não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços”*, ressaltando que a fiscal técnica da contratante deve ter acesso às dependências da contratada, para aferição do cumprimento das normas de higiene e paramentação, após a assinatura do contrato.

Apesar disso, no capítulo referente à qualificação técnica, o aludido item 8.5.1, em descompasso com a previsão acima, reclama a apresentação de declaração alusiva à vistoria prévia a ser realizada pelas licitantes no local de execução do serviço (Art. 62, § 2º, da NLLC), que pode ser substituída por declaração formal assinada por responsável técnico, conforme o subsequente item 8.5.2¹⁹ (grifei).

Tal discrepância entre as disposições do Termo de Referência confere incerteza se a vistoria prévia será ou não necessária.

¹⁹ 8.5.2. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação

Ademais, com o MPC, entendo não se mostrar apropriada a anunciada substituição da palavra “local” por “legais” no aludido item 8.5.1, pois *“denota que o conhecimento prévio do local de execução dos serviços não seria imprescindível, o que dispensaria a realização de vistoria prévia”*

Nesta toada, necessário que a Prefeitura defina, de forma clara, se será facultada a realização de visita técnica às licitantes.

3.7 Outrossim, independentemente da obrigatoriedade de vistoria prévia, prospera a apontada carência de elementos essenciais ao correto dimensionamento do objeto licitado.

Impende destacar que o instrumento convocatório vincula as partes às normas e condições nele estabelecidas, devendo, por isso, ser claro e objetivo, de modo que as licitantes tenham condições plenas de formular adequadamente suas propostas, considerando o custo da operação ante as informações constantes no edital.

No entanto, não é o que ocorre no presente caso.

Conforme apontado pelo Órgão Ministerial, *“embora conste do edital que o ‘objeto também inclui a higienização das dependências, utensílios e equipamentos’ (item 1.3.7 do Termo de Referência) e que a contratada será responsável, por exemplo, pelo ‘Fornecimento de equipamentos para o armazenamento, conservação, distribuição, refrigeração, conforme a disponibilidade de espaço da CONTRATANTE (rechaud, buffet, freezer vertical ou horizontal, hot box, embalagens térmicas, carrinhos de transporte térmicos etc)’ (item 1.3.5 do Termo de Referência) e pela ‘limpeza da Unidade de Alimentação e Nutrição (parte interna do refeitório) a higienização do ambiente antes e após as refeições servidas’ (item 5.2.10.2 do Termo de Referência), não há quaisquer especificações dos locais, utensílios e equipamentos mencionados, o que poderá prejudicar o correto dimensionamento dos custos de execução do serviço.”*

Tal conduta não se coaduna com o procedimento licitatório, o qual impõe à Administração indicar, ainda que de maneira aproximada, a sua pretensão, não podendo ser fixada aleatoriamente, sem quaisquer parâmetros.

Desta forma, necessário que o ato convocatório passe a disponibilizar todos os elementos essenciais à adequada formulação das propostas.

3.8 Por fim, considero improcedente a alegada ausência de levantamento de mercado, porquanto esclarecido pela Administração que a análise das alternativas possíveis para a escolha do tipo de solução a contratar consta do Estudo Técnico Preliminar (ETP), sendo que a Lei 14.133/2021 não exige sua publicação ou que conste como anexo do edital.

Todavia, pertinente a observação do MPC de que os itens 2.1 e 3.1 do Termo de Referência mencionam que os Estudos Técnicos Preliminares constam como “*apêndice deste Termo de referência*”, de modo que recomendo à Administração que insira os referidos Estudos dentre os anexos do ato convocatório ou exclua os dispositivos em questão.

3.9 Posto isto, circunscrito às questões analisadas, considero **parcialmente procedentes** as impugnações, determinando que a Administração adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial:

- a) adequar a exigência de atestados de capacidade técnica à Súmula nº 30 desta Corte;
- b) tornar obrigatória a apresentação de alvará sanitário;
- c) excluir a requisição de certidão negativa de insolvência civil;
- d) permitir a subcontratação dos serviços acessórios abarcados no objeto;

- e) adequar a base de cálculo para a prova do patrimônio líquido mínimo e para a garantia contratual;
- f) eliminar a alocação de todos os ônus decorrentes de eventos imprevisíveis e atípicos à futura contratada;
- g) definir, de forma clara, se será facultada a realização de visita técnica às licitantes; e
- h) disponibilizar todas as informações essenciais para o correto dimensionamento do objeto e a consequente elaboração de propostas.

Recomendo, outrossim, que a Administração reavalie os termos dos itens 2.1 e 3.1 do Termo de Referência, a fim de inserir os Estudos neles mencionados dentre os anexos do ato convocatório ou excluir os dispositivos em questão.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 05 de fevereiro de 2025.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
CONSELHEIRO